

1501688-71.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... para uso.

A materialidade do delito de tráfico restou sobejamente comprovada. O laudo acerca dos rádios comunicadores encontrados com os réus e o adolescente e os demais elementos de prova colhidos em audiência e no curso do feito, apontam a prática reiterada do crime de tráfico, restando isolada a negativa dos acusados e a tentativa de escusar seus comparsas por parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501688-71.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501688-71.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176097/2022 - DEL.POL.CAJAMAR, 25843343 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2176097 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIANO MARCIO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Kaique Jhonatan Domingues Pereira e Flaviano Marcio Nascimento foram denunciados como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inc. VI, todos da Lei 11.343/06, na forma de concurso material de infrações, pois segundo a denúncia (fls. 203/205), desde data incerta até 29/06/2022, na Estrada da Roseira, nº 280, Roseira, em Franco da Rocha, os denunciados e o adolescente João Paulo Oliveira Maciel, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes de tráfico ilícito de entorpecente. Igualmente consta que, em 29/06/2022, por volta das 13h30min, na Estrada da Roseira, nº 280, Roseira, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, os denunciados e o adolescente traziam consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, (i) 209,1g de cocaína, dividida em 272 tubos plásticos, (ii) 2,8g de cocaína em forma de crack, fracionada em 12 unidades, e (iii) 242,5g de tetrahidrocannabinol, dividida em 21 porções, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação preliminar (fls. 20/22) e laudo químico-toxicológico (fls. 191/193), o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19/06/2022 (fl. 206).

Promovida a citação (fls. 317 e 320), o réu Kaique apresentou resposta à acusação (fls. 254/255).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 252), na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório.

Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/14), laudo químico-toxicológico (fls. 191/193), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografias (fls. 55/58), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

A autoria é certa.

Quando ouvido perante a autoridade policial, o réu Kaique Jhonatan Domingues Pereira disse que estava em sua residência na Rua Estrada da Boiada, nº 370, no bairro Roseira. O réu relata que é usuário de drogas do tipo maconha e que na data dos fatos resolveu ir até o local perto de sua residência onde é conhecido por venda e tráfico de drogas. Ao chegar perto do local, avistou alguns indivíduos correndo e como já tinha uma passagem por roubo quando era menor, ficou com medo e passou a correr junto com os indivíduos, momento em que encontrou os policiais em sua frente e logo se deitou ao chão e sentiu um cachorro mordendo seu braço direito. Relata que estava em posse de seu aparelho celular da marca Motorola E20, na cor azul e uma quantia em dinheiro no valor de R\$ 75,00. Os policiais então encaminharam-no ao UPA desta cidade de Cajamar para ser atendido e ao ser liberado, foi trazido à Delegacia para fazer o registro dos fatos (fl. 08).

Em juízo, o réu Kaique disse que os fatos são falsos. No dia dos fatos, estava na construção com seu pai e foi ao local comprar maconha. As pessoas saíram correndo e o depoente correu junto. Não comprou a maconha. Enquanto correu, viu os policiais e parou quando foi dada a voz de parada. Não viu o momento em que a droga foi abordado. Não viu Flaviano e nem o adolescente, mas apenas os encontrou na viatura e não conhecia os demais abordados e nem os policiais militares que fizeram sua prisão. Estava trabalhando em cima da casa de seu pai. Estava desempregado. Faz uso apenas de maconha. Mora junto com uma pessoa e não tem filhos. Estudou até o 1º ano do ensino médio. Não respondeu a nenhum processo criminal. Trabalhou com carteira assinada até dezembro. Pagava aluguel com o dinheiro da rescisão. Recebia R\$75,00 por dia trabalhando com seu pai. Estava construindo o imóvel desde quando saiu da antiga empresa. Foi abordado pelo policial e o cachorro o conteve quando estava no chão.

O corréu Flaviano Marcio Nascimento, em solo policial, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio (fl. 09).

Em juízo, o réu Flaviano disse que os fatos são falsos. Disse que os fatos são falsos. Disse que estava trabalhando e, depois do trabalho, foi ao local comprar crack. Viu uma viatura e foi abordado. Disse ao policial que estava foragido. O policial apareceu com uma sacola de droga e, disse que, como não encontrou o traficante a culpa seria deles. Chegou sozinho na delegacia e só encontrou os demais na delegacia. Estava foragido pelo crime de tráfico de drogas. Faz uso de crack e cocaína. Trabalhava na área de jardinagem e estava há um mês afastado, fazendo bicos de carga e descarga de mercadorias.

A versão apresentada pelos réus em juízo não guarda consonância com as provas colhidas ao longo do feito.

O policial militar André Luiz Ferreira da Silva disse que estava em patrulhamento com a VTR M- 26-871, juntamente com seu colega de serviço Leôncio e com o motorista Danilo, quando adentraram em uma rua no bairro do Calcária, prosseguindo a pé, com

o objetivo de fazer o cerco. A VTR prosseguiu com o motorista até a Estrada da Roseira, próximo ao nº 280 – local já conhecido por tráfico de drogas – momento em que os três indivíduos foram de encontro aos policiais que estavam a pé, quando avistaram três suspeito correndo pela trilha, sendo que dois foram pegos, sendo o adolescente João Paulo Oliveira Maciel e o outro Flaviano Marcio Nascimento. O terceiro que conseguiu correr. O Policial Militar André, que estava com o cachorro da guarnição, deu o comando para que o cachorro fizesse a imobilização do Kaique Jhonatan Domingues Pereira, que desobedeceu a ordem de parada. O Policial relatou que encontrou em poder de Flaviano uma sacola na cor verde, contendo várias porções de substâncias do tipo 12 porções de maconha, 234 porções de cocaína e em seus bolsos a quantia no valor de R\$ 172,00, um aparelho celular da marca Motorola e um rádio comunicador em seu pescoço. Em pesquisa nos sistemas policiais, verificou-se que Flaviano é procurado pela justiça, pois pesa em seu desfavor mandado de prisão nº 1500860-80.2019.8.26.0544, expedido pela 1ª Vara Judicial do Foro de Cajamar, pelo delito cometido art. 33, caput, c/c o art. 40, caput, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 150, §1º do CP. Já Kaique estava portando uma sacola na cor verde e no interior da sacola constava 9 porções de maconha, 12 porções de crack e mais 38 porções de cocaína. Em seus bolsos foi encontrado a quantia de R\$ 203,00, um aparelho celular da marca Motorola e um rádio comunicador em seu pescoço, e com o menor João Paulo foi encontrado somente um rádio comunicador em seu pescoço. O Policial Militar, ao questionar os indivíduos sobre as drogas, dinheiro e os rádios comunicadores, os três indivíduos confirmaram que estavam no tráfico vendendo drogas ali no local. No decorrer da ocorrência foi pedido apoio as VTR M26-177 M26-307 M26-002 M26310 M26-325 e M26-326. Kaique foi encaminhado ao UPA desta cidade para ser medicado. Diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu os três indivíduos à Delegacia para fazer o registro dos fatos (fl. 03).

Em juízo, a testemunha disse que é policial militar e, no dia dos fatos, estavam em operação em local conhecido pela venda de drogas. Seguiu por uma trilha que daria em boca de fumo enquanto o motorista seguiu por outro local, provocando a fuga dos criminosos. Dois dos indivíduos que fugiram foram pegos por seu parceiros. Um outro indivíduo tentou fugir e não obedeceu a ordem de parada sendo enviado o cão que o mordeu. Em poder desse indivíduo encontraram uma sacola com entorpecentes, cerca de R\$100,00 em dinheiro, um aparelho celular e um rádio comunicador. Em poder de Flaviano foi encontrado mais entorpecentes e um rádio comunicador. Em poder do menor foi encontrado outro rádio comunicador. Os rádios estavam na mesma frequência e, no local, confessaram a traficância. Além de entorpecentes, com Flaviano foi encontrada uma quantia em dinheiro. Kaique correu com a sacola nas mãos e foi abordado com a sacola em seu poder. Quando deu a ordem de parada a Kaique estava a cerca de dez metros dele. Não conhecia nenhum dos três abordados antes desses fatos.

Em solo policial, o policial militar Filipi Jaworske Leoncio confirmou o relato de seu colega André Luiz nos mesmos exatos termos (fl. 05). Em juízo, disse que, no dia dos fatos, estava em operação de combate ao tráfico de drogas. Fizeram um cerco policial em ponto de venda de drogas, o que motivou a fuga de três indivíduos que vieram na direção dos policiais. O depoente conteve Flaviano e um adolescente. O terceiro indivíduo foi imobilizado com auxílio do cão por seu parceiro. Em poder de Flaviano, estava um rádio comunicador que estava na mesma frequência do rádio encontrado em poder do adolescente e de Kaique. Havia entorpecente e dinheiro em poder de Kaique e Flaviano, além dos rádio comunicadores. O adolescente admitiu que estava atuando como "olheiro". Os três indivíduos correram juntos em direção aos policiais. Não se recorda de cor de sacola, mas pelo que se recorda o entorpecente estava em uma sacola. Enquanto foi dado comando ao cão o depoente estava ocupado contendo os outros dois indivíduos. No momento da abordagem, estava o depoente e seu parceiro, tendo o auxílio do motorista da guarnição. Mais viaturas chegaram ao local depois em apoio. Não conhecia os indivíduos que foram presos antes desses fatos.

Já o adolescente João Paulo Oliveira Maciel, perante a autoridade policial, disse que a tarde foi dar um rolê em Jordanésia e aproveitou para comprar uma maconha, na Estrada da Roseira. No local, foi convidado por um indivíduo para ficar de olheiro,

onde este lhe entregou um rádio de comunicação (HT). Assim que o indivíduo lhe entregou o rádio comunicação, o declarante foi por trás da comunidade e ficou na parte alta para avisar aos traficantes locais quando alguma viatura policial adentrasse. Afirmou que não quer falar o nome do indivíduo que lhe convidou a ficar de olheiro e disse que aceitou o serviço por estar precisando de dinheiro, fato este negado pela curadora. Ao perceber a presença dos policiais militares, tentou se evadir, todavia foi alcançado por eles e confessou estar de olheiro para os traficantes locais. Alega que foi agredido e ameaçado pelos policiais, porém, não está machucado. Nega conhecer o Flaviano Márcio Nascimento e o Kaique Jhonatan Domingues Pereira e não viu quando os policiais militares os prenderam (fl. 07). Em juízo, o adolescente disse que tem 17 anos. Disse que, no dia dos fatos, foi ao local comprar entorpecente e acabou atuando como olheiro, o que o fez por três dias. Não sabia como a droga era entregue. Não ficou internado na fundação casa. Ficou 33 dias na Fundação Casa e encontra-se em cumprimento de Liberdade Assistida. Não viu o entorpecente. Não viu entorpecente sendo vendida. Com a chegada da polícia tinha que avisar pelo rádio que recebera. Não viu quem comercializava drogas no local. Não conhecia Kaique. Não morava nas proximidades. Não conhece Flaviano. Passava as informações via rádio. No dia que subiu viu quem eram as pessoas vendendo drogas, mas não eram os que foram presos. Tinha que avisar pelo rádio da aproximação dos policiais. Não teve que ajustar a frequência do rádio, tendo o equipamento lhe sido entregue pronto para uso.

A materialidade do delito de tráfico restou sobejamente comprovada. O laudo acerca dos rádios comunicadores encontrados com os réus e o adolescente e os demais elementos de prova colhidos em audiência e no curso do feito, apontam a prática reiterada do crime de tráfico, restando isolada a negativa dos acusados e a tentativa de escusar seus comparsas por parte do adolescente apreendido na ocasião. Pelo relato da prova oral, os réus Kaique e Flaviano foram presos de posse de expressiva quantidade de entorpecentes, além do rádio comunicador, sendo evidente que encontravam-se no local realizando o tráfico de drogas. João Paulo, contatado para atuar como “olheiro” na ocasião, ao verificar a presença da viatura policial, avisou-lhes desta aproximação, razão pela qual empreenderam fuga em conjunto. É evidente que o adolescente atue com interesse em afastar a culpabilidade de seus comparsas, prática comum em crimes dessa natureza face às graves retaliações impostas pela criminalidade.

No entanto, os policiais, testemunhas isentas, relataram de modo seguro que os acusados estavam de posse dos rádios comunicadores e dos entorpecentes, em quantidade e diversidade absolutamente incompatíveis com as destinadas ao uso próprio. Além disso, o fato de estarem de posse dos rádios comunicadores em frequência una indica a clara vinculação e concurso para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Desta feita, não se vislumbra elementos que possam elidir os depoimentos dos agentes da prisão, tal a distorção das versões apresentadas pelos acusados e contradições nelas encontradas.

É de se frisar que, além das contradições apontadas nas versões dos réus, nenhum esclarecimento plausível ofereceram eles para justificar a quantidade e variedade de droga apreendidas, tampouco para os rádios comunicadores encontrados, bem como os valores e os celulares que foram apreendidos pela Polícia Militar.

Quanto aos depoimentos apresentados pelos policiais, além de coadunarem com os demais elementos, a análise dos autos revela que não há motivos para não se atribuir credibilidade aos depoimentos dos policiais ouvidos no presente feito, haja vista que eles são coerentes e harmônicos entre si, bem como porque não se demonstrou que eles poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos acusados ou, inclusive, forjado uma situação incriminatória aos réus. O simples fato de tais testemunhas serem policiais não as torna desmerecedoras de confiança, de forma que caberia aos réus a comprovação de razões ponderáveis para tanto, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por policiais, sejam civis ou militares, possuem presunção juris tantum de veracidade e legitimidade,

afastável somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário.

A propósito:

Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria.

Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54) (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel. Willian Campos - j. 27/05/2014 - votação unânime, grifei).

Necessário ressaltar a importância das falas destes profissionais que, escolhidos pelo Estado para desempenhar nobre função, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque não restou provada qualquer intenção dos servidores em, de alguma forma, prejudicar o réu.

Assim, não se pode desmerecer o depoimento de agentes policiais apenas por sua condição de agente da lei, consoante lição do mestre ARY BELFORT, que afirma: 'A tese da insuficiência testemunhal quando emane de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. (RJTJESP 136/477).

Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções.

Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente.

Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas testemunhas são os próprios policiais condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba sendo determinante para a condenação. (Apelação nº 0006119-11.2012.8.26.0372 - 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP - Rel. Edison Brandão - julgado em 22 de abril de 2014 - votação unânime, grifei).

Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito (Apelação nº 0000907-35.2012.8.26.0428 - 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP - Rel. Sérgio Coelho - j. 29/05/2014 - votação unânime, grifei).

Os relatos dos policiais ouvidos no presente feito, bem como o robusto conjunto documental colacionado, deixam evidente que as drogas descritas na denúncia eram de propriedade dos réus, que se associavam para fins de prática de traficância.

Não há dúvidas, ainda, acerca da destinação de tais entorpecentes, haja vista que as circunstâncias da prisão, aliadas à natureza das drogas que foram apreendidas e aos três rádios comunicadores encontrados com os réus comprovam, de maneira

inequívoca, a finalidade mercantil.

Consigne-se que, para a caracterização da traficância, a jurisprudência é remansosa acerca da desnecessidade de identificação de qualquer suposto cliente para o qual a droga se destinaria, também não sendo necessário que o agente seja observado ou abordado enquanto praticava atos efetivos de mercancia.

Saliente-se, ademais, que ainda que os réus, por hipótese, argumentem que são usuários, tal alegação não afasta a responsabilidade penal dos acusados, principalmente porque, ainda que o seja, a atividade associativa ficou sobejamente demonstrada.

Por estarem comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitivas, bem como o fato de que as substâncias entorpecentes apreendidas tinham destinação mercantil, a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, entendo que este não restou comprovado de modo suficiente em juízo. A presença de rádio comunicadores, por certo, indica indício de vínculo entre os agentes, mas tal elemento isolado não é suficiente a amparar a condenação. Não há elementos que comprovem a estabilidade, constância e divisão de tarefas que caracterizariam a associação em questão. De fato, houve a constatação de concurso de agentes para a prática do crime, inclusive com a participação de adolescente, o que implica em aumento da pena a ser aplicada, mas o conjunto probatório carece de elementos mais robustos a amparar condenação pelo crime do art. 35 da lei de Drogas.

Sem prejuízo, restou devidamente comprovada a participação de adolescente na empreitada criminosa dos réus (conforme comprovam os depoimentos em solo policial em juízo dos do adolescente e das testemunhas), sendo de rigor a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI da Lei Antidrogas.

Quanto ao réu Kaique Jhonatan Domingues Pereira:

Atenda às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes (fl. 303). A quantidade de drogas apreendidas é elevada (209,1g de cocaína, 2,8g de cocaína em forma de crack 242,5g de tetrahydrocannabinol - fls. 15/16), o que justifica a elevação do crime em patamar superior ao mínimo. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Portanto, elevo a pena base em 1/8 acima do mínimo, fixando-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Presente a atenuante da menoridade penal relativa (conforme demonstra a data de nascimento indicado à fl. 10), razão pela qual a pena retorna ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, de rigor a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, eis que comprovado o envolvimento do adolescente João Paulo Oliveira Maciel no tráfico realizado na Estrada da Roseira. Assim, aumenta-se a pena base em 1/6, perfazendo as pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inaplicável a causa de diminuição de pena no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, eis que comprovado que o réu atuava de modo constante e organizado na traficância, ainda que afastada a pena do crime de associação.

No caso, verifica-se que os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da causa de diminuição de pena.

No entanto, a quantidade da droga apreendida e a presença de rádio comunicadores entre os agentes, demonstram, por si só, de forma evidente, que ele fazia daquele comércio espúrio conduta habitual, independentemente da primariedade. A considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas na posse do réu, demandam maior censura, com resposta severa do Estado, o que sugere dedicação à atividade criminosa, não podendo, por conseguinte, ser considerado como "pequeno traficante".

O réu tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico,

considerável quantidade de maconha, cocaína e "crack", além da posse de rádios de comunicação, sendo que tais circunstância, no caso, também não indica a conveniência de redução das penas com a aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no artigo 33, § quarto, da Lei Federal 11343/06. Em que pese a primariedade, o acusado se dedicava às atividades criminosas.

Palpável a maior reprovabilidade da conduta, prestando-se os entorpecentes, pela quantidade, diversidade e natureza, a lesionar em maior intensidade a saúde pública, bem jurídico protegido pelo artigo 33, da Lei Federal 11343/2006. Assim, resultou demonstrado que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Isso porque ele foi flagrado tendo em depósito, trazendo consigo e guardando elevada quantidade de maconha, cocaína e "crack", não havendo provas que o acusado se enquadre nas características de um traficante meramente eventual.

O tráfico e a dependência química são os maiores responsáveis pela prática de diversos outros crimes graves e violentos, como furto, roubo e homicídio. Ademais, deve-se ter em conta que não é crível que um traficante eventual, esporádico, tenha em depósito, traga consigo e guarde além desses entorpecentes, rádios de comunicação, o que revela habitualidade criminosa, no comércio clandestino, eis que fazia da prática delitiva o seu meio de vida, a comprovar que ele não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, não fazendo jus à aplicação da referida causa de diminuição prevista na Lei de Tóxicos.

Aliás, quem não se dedica às atividades criminosas não conseguiria, sem mais nem menos, estar em poder dessa considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, voltadas à venda, não devendo, portanto, ser aplicado o redutor ao apelante.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante ausência de comprovação da situação econômica do acusado.

A pena será cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do que determina o art. 33 do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada.

Incabível a aplicação do art. 44 do Código Penal pela pena privativa de liberdade ser superior a 4 anos. Sendo a pena superior a 2 anos, resta afastada a possibilidade de suspensão condicional da pena (art. 77).

Quanto ao réu Flaviano Marcio Nascimento:

Atenda às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu possui Maus antecedentes (autos nº 0000042-31.2014.8.26.0108/0001729-88.2015.8.26.0502 - fl. 299 - pena cumprida em 01/09/2016). A quantidade de drogas apreendidas é elevada (209,1g de cocaína, 2,8g de cocaína em forma de crack 242,5g de tetrahidrocannabinol - fls. 15/16), o que justifica a elevação do crime em patamar superior ao mínimo. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Portanto, elevo a pena base em 1/6 acima do mínimo, fixando-as em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e nem agravantes (anoto que apesar de à fl. 299 constar a existência da condenação proferida nos autos nº 1500860-80.2019.8.26.0544, a apelação ainda não foi julgada). Assim, as penas intermediárias permanecem idênticas às penas bases.

Na terceira fase, de rigor a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, eis que comprovado o envolvimento do adolescente João Paulo Oliveira Maciel no tráfico realizado na Estrada da Roseira. Assim, aumenta-se a pena base em 1/6, perfazendo as penas definitivas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Inaplicável a causa de diminuição de pena no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, eis que o réu possui Maus antecedentes na prática de crime da mesma natureza.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante ausência de comprovação da situação econômica do acusado.

A pena será cumprida no regime inicial fechado. A despeito de ser tecnicamente primário, verifico-se que o réu foi preso de posse de expressiva quantidade de entorpecentes, além de um rádio comunicador, mesmo tendo cumprido pena por crime de mesma natureza. Assim sendo, mostra-se evidente que sua ressocialização não

mostrou-se efetiva, sendo necessário maior rigor na fixação do regime inicial. Incabível a aplicação do art. 44 do Código Penal pela pena privativa de liberdade ser superior a 4 anos. Sendo a pena superior a 2 anos, resta afastada a possibilidade de suspensão condicional da pena (art. 77).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar os réus Kaique Jhonatan Domingues Pereira como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. a majorante do art. 40, inc. VI, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

E Flaviano Marcio Nascimento como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. a majorante do art. 40, inc. VI, à pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.

ABSOLVO os acusados da imputação prevista no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, c.c. a majorante do art. 40, inc. VI, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Mantidas as condições da decretação da preventiva, os réus não poderão aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções. A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença. Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Defiro a gratuidade aos réus, antes a condição financeira demonstrada na AIJ

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento desta sentença.

Expeçam-se certidão de honorários aos defensores dativos, se eles tiverem atuado no feito.

P.I.C.

Franco da Rocha, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA